

1509907-51.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... previsto no caput do mesmo artigo, de tráfico ilícito de drogas.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente, tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico nas modalidades de "guardar", "semear" e "cultivar" as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509907-51.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509907-51.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAUL DOS SANTOS LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

RAUL DOS SANTOS LOPES foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput e § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, inciso II, alínea "j)", do Código penal, porque, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 15 horas, durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 e Decreto Federal nº 06/2020 (decretos de calamidade pública), Rua Doutor Carmelo Zamitti Mammana, nº 132, Mandaqui, nesta cidade e Comarca, guardava, semeava e cultivava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 45 (quarenta e cinco) vasos contendo pés de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de droga popularmente conhecida como "maconha", bem como 26 (vinte e seis) copos plásticos contendo mudas de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de droga popularmente conhecida como "maconha", com peso de 6,1 gramas, 14,9 quilogramas e 0,5 gramas, além de 10 (dez) vasos contendo terra e outra substância a ser identificada pelo laudo definitivo, com peso de 46,3 quilogramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates e memoriais.

Auto de Exibição e Apreensão das plantas que se constituem em matérias-primas para a preparação de drogas, a fls. 12.

Laudos de Constatação das plantas apreendidas, a fls. 18/20 e 21/24.

Laudo Pericial do local dos fatos, a fls. 131/140.

Laudos de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 141/143 e fls. 144/146.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, bom enfrentar a matéria preliminar suscitada pela combativa Defesa, referente à alegada ilegalidade da prova.

Ora, sempre respeitado entendimento contrário, o flagrante não está eivado de nulidade absoluta, em decorrência da alegada violação ao domicílio do agente, donde, então, não há qualquer vício na prova produzida.

Isso porque, consabido, nenhum direito é absoluto, nem mesmo os direitos fundamentais, constitucionalmente previstos, eis que limitados, inclusive, por outros direitos de igual envergadura axiológica.

Com efeito, no caso em tela, bem afirmaram as testemunhas policiais terem recebido informes de que no local havia a prática do tráfico de drogas, cultivo de entorpecentes para fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

De toda forma, certo é que, buscando averiguar tal notícia crime, a equipe policial rumou ao local e montou campana, a princípio, não verificando qualquer movimentação estranha de pessoas, até que, em determinado tempo, se depararam com o acionado saindo da residência, ele que se portou de forma suspeita, aparentemente preocupado, o que motivou sua abordagem para averiguação, ele que trazia consigo uma pequena muda do que, aparentemente, se tratava de maconha. Assim, com sua autorização incursionaram no local, sede em que verificaram, não só uma grande gama de mudas pequenas, inúmeros vasos de pés de maconha em estágio avançado de cultivo, numa espécie de estufa, com ar condicionado.

Interessante que tais circunstâncias encontram-se bem demonstradas não só pelas fotos de fls. 26/33, como, também, pelo laudo pericial de fls. 131/140.

Neste contexto, verifica-se que havia motivos idôneos à averiguação, motivos estes que, ao final, se confirmaram, visto que apreendida grande quantidade de vasos e mudas de maconha, em cultivo sério, com preparação.

Assim, e em se tratando o tráfico de drogas de crime permanente, tem-se que o flagrante se protraí no tempo, podendo a incursão em residência, ainda que habitada, ser realizada em qualquer horário do dia ou da noite, nos exatos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência em uníssono:

Afinal, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de tráfico de drogas nas modalidades guardar e ter em depósito é de natureza permanente (cf. art. 303 do Código de Proc. Penal), assim entendido aquele cuja consumação se protraí no tempo, não se exigindo a prévia obtenção de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do suspeito quando tal se faz necessário para fazer cessar a atividade criminosa, algo que a ordem jurídica considera factível não apenas por membros das corporações de segurança, mas também por "qualquer do povo" (cf. art. 301 do CPP), dada a situação de flagrância.

Nesse sentido, confirmam-se as seguintes ementas [sem destaques nos originais]:

"A jurisprudência desta Corte é segura no sentido que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente. Precedentes. [...] No que tange à suposta ilegalidade da prisão em flagrante e das provas colhidas durante a diligência policial, o entendimento perfilhado pela Corte 'a quo' está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da

Constituição Federal. Ainda, a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial. Precedentes. [...] Writ não conhecido. (HC 404.980/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)“

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1574795/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016)“

“[...] Este Tribunal tem reputado dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. (RHC 54.972/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).”¹

E ainda, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Habeas Corpus com pedido de liminar - Tráfico ilícito - Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Alegação de ilegalidade da constrição - Ingresso em domicílio sem mandado de busca e apreensão - Inexistência de eiva - Paciente preso em flagrante em decorrência do cometimento, em tese, de crime de natureza permanente (CF art. 5º, XI, segunda parte, e CPP, art. 303) - Decisão motivada e que atende às exigências legais (CF, arts. 5º, LXI, e 93, IX; CPP, arts. 283, 310 e 315) - Presença dos requisitos previstos no art. 312, caput, do mesmo codex. (...) Ordem denegada.”²

Ademais, a atuação policial lícita, verdade seja dita, não reclama sejam conclamadas testemunhas estranhas ao quadro policial para tornar legítima a atuação.

Destarte, pelo exposto, tenho como absolutamente lícita a ação dos policiais civis, não havendo se falar em violação de domicílio, eis que a propriedade imóvel não recebeu proteção constitucional para que fosse utilizada na prática de crimes, o que seria verdadeiramente teratológico.

Ao mérito, então, o que verdadeiramente interessa.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão, a fls. 12; Laudos de Constatação das plantas apreendidas, a fls. 18/20 e 21/24; Laudo Pericial do local dos fatos, a fls. 131/140; e Laudos de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 141/143 e fls. 144/146, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de plantas que se constituem em matérias-primas para a preparação de drogas, especificamente de “maconha” (tetrahidrocannabinol).

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua conduta ativa ao semear, cultivar e guardar as matérias-primas em questão, com evidente propósito de entrega da droga ao consumo de terceiros, especialmente em se considerando a quantidade de plantas que eram cultivadas e todo o engenhoso aparato utilizado pelo réu para a produção da substância, inclusive se valendo de uma estufa improvisada.

Interrogado na fase policial, o acionado optou pelo silêncio, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 07).

Em audiência judicial, admitiu a posse de parcela do plantio, que afirmou ser destinado ao uso pessoal.

Contudo, pese embora o esforço de argumentação da combativa Defesa, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida!

Interessante que não fez prova mínima e séria de seu vício, tampouco do exercício de atividade lícita que lhe rendesse algum sustento, a tanto não se prestando o documento de fls. 95, que contrasta com a própria afirmação do réu em

interrogatório, revelando embuste.

Ora, consoante afirmou em interrogatório, se dedica a atividade de ajudante geral. Já o referido documento, mera declaração, quando se esperava o registro em CTPS, afirma que o acionado trabalha como garçom, se segunda a sábado, no horário das 9:00 às 20:00 horas, com folgas quatro vezes por semana.

Doutro lado, temos os relatos precisos e harmônicos dos policiais civis responsáveis pela prisão do acusado.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas José Ricardo Quevedo Soares e Eduardo Rodrigues Santos declararam, em versões de todo harmônicas, que, na data em questão, estavam verificando uma denúncia anônima acerca de um rapaz que cultivava uma plantação de "maconha" em sua própria residência, sendo que o produto desse plantio se destinava ao abastecimento de pontos de vendas de entorpecentes na região de São Mateus, área circunscricional do 49ºD.P. De posse dessas informações, comunicadas à autoridade policial, e autorizada a diligência, rumaram ao local e, durante campana velada, visualizaram um rapaz, identificado posteriormente como sendo RAUL DOS SANTOS LOPES, a quem não conheciam no exato momento em que deixava as dependências de um imóvel ali situado com algo nas mãos, não se sabendo, ao certo, do que se tratava. No entanto, diante da atitude suspeita de tal indivíduo, deliberaram por sua abordagem, realizando procedimento de busca pessoal. Restou apurado que aquilo que RAUL trazia consigo era um pequeno vaso contendo algumas sementes, recém germinadas, cujas características assemelhavam-se às de pés da planta vulgarmente conhecida por "maconha". Indagado sobre a procedência daquela planta, RAUL informou que estaria a caminho para "fazer uma entrega", não tecendo maiores informações para quem a estaria levando, bem como qual seria o local dessa entrega. No entanto, ao ser questionado acerca da origem daquela muda, RAUL informou que cultivava uma plantação do entorpecente em sua residência. Ato contínuo, e com autorização prévia e verbal de RAUL, os depoentes ingressaram nas dependências do imóvel do ora acusado, apurando a veracidade da denúncia, na medida em que localizadas diversas plantas e mudas da droga (maconha), distribuídas em vários vasos de pequeno, médio e grande porte, com diversos tamanhos de pés da erva citada, incluindo estrutura adequada para o seu cultivo, com diversos equipamentos destinados ao desenvolvimento desse tipo de planta, como aparelho de ar condicionado, numa espécie de estufa.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado guardava, semeava e cultivava plantas que constituem matérias-primas para a preparação da droga comumente conhecida como maconha, consistentes em 45 vasos contendo pés das referidas plantas e 26 copos plásticos contendo mudas da mesma planta, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e ainda com evidente destinação mercantil, mormente porque absolutamente incompatível o cultivo de tamanha quantidade de plantas destinadas à preparação de drogas unicamente para seu deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito, como acima destacado.

Além disso, conforme laudo do local dos fatos, nota-se que o réu transformou sua residência em um verdadeiro laboratório destinado ao plantio, colheita e transformação das plantas em drogas, utilizando um dos quartos exclusivamente como estufa, com iluminação e ventilação apropriadas ao cultivo da erva, havendo diversos vasos da planta dispostos na sala, além de outros espelhados pelo imóvel. Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

A grande quantidade de matérias-primas destinadas à preparação das drogas apreendidas, cada pé de plantio originando cerca de 30/40 gramas de droga (consoante informou em seu interrogatório), a encerrar mais de um quilo de entorpecente, as circunstâncias do flagrante, verificada a engenhosidade do acusado na transformação de sua casa em verdadeira estufa para a produção de maconha, semeando, cultivando e guardando as plantas, os depoimentos firmes dos policiais que o abordaram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão

inarredável de que o acusado efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória, devendo responder pela figura prevista no art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/06, equiparada ao crime previsto no caput do mesmo artigo, de tráfico ilícito de drogas.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente, tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico nas modalidades de “guardar”, “semear” e “cultivar” as matérias-primas destinadas à preparação de maconha.

Assim, a meu modesto sentir, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente desfavoráveis. Não obstante, levando-se em consideração a elevada quantidade de plantas e mudas apreendidas na residência do acionado, bem como o aparato existente no imóvel, indicando produção da droga em escala considerável e com certo profissionalismo, inclusive, de rigor sejam suas penas-base fixadas em patamar 1/6 superior ao mínimo legal, alcançando o cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a quinhentos e oitenta e três dias multa.

Em segunda fase, entendo ausentes circunstâncias atenuantes.

A assunção da posse de apenas parcela do plantio, aliada à negativa da destinação mercantil, não revela confissão plena, e, sim, mera confissão qualificada, com viés de ilusão ao Juízo, não se prestando a favorece-lo (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500998-40.2020.8.26.0535, rel. Des. Camilo Léllis, j. 03.08.2021, V.U.; STJ, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/08/2013, T5 - QUINTA TURMA).

Ademais, sua admissão, na forma como lançada nos autos, não foi utilizada como critério de formulação do juízo de convicção acerca de sua responsabilidade pelo delito imputado.

Doutro lado, de rigor o reconhecimento da agravante decorrente da reincidência, conforme apontam os documentos de fls. 110/117, 118/119 e 198/199, indicando que a extinção da punibilidade do acusado referente à sua anterior condenação criminal se deu em 18/10/2019, portanto há menos de cinco anos da data dos fatos apurados neste processo.

Doutro lado, revendo posicionamento anterior, me convenço que na espécie não seja o caso de reconhecer a agravante descrita na denúncia (crime praticado durante período de calamidade pública), ausente, na prova, qualquer indicativo concreto de que o acionado se prevaleceu da pandemia para a prática do crime em questão, o que seria imprescindível a render espaço para reconhecimento da agravante.

Confira-se: Agravante prevista pelo art. 61, II, alínea j, do CP não prospera. A situação de calamidade em nada facilitou a ação criminosa, não havendo que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento do acusado daquela situação. (Apelação Criminal nº 1511782-27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de março de 2022, rel. Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli)

Ou seja, ausente prova do nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta imputada ao acionado, incomprovado, então, que o acionado tenha se valido de alguma fragilidade ensejada pela pandemia para praticar o crime, seu reconhecimento se mostra impossível.

Sobre o tema, ainda: Habeas Corpus nº 625645-SP, rel. Ministros Félix Fischer; AgRg no Habeas Corpus nº 717.298-SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas; AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 669.508/SP, Rel.

Ministro Sebastião Reis Junior.

Assim, frente à reincidência do acusado, majoro suas reprimendas iniciais em 1/6, culminando no cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (doze) dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, fixados estes no patamar mínimo previsto em lei, penas estas que torno definitivas, em não havendo causas de aumento ou diminuição de penas a serem consideradas em ulterior etapa.

Finalmente, consigno ser inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em se tratando de acusado reincidente.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado, em atenção ao parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, único suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta, mormente em se tratando de acionado reincidente e lhe sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

No que tange a eventual substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, observo que o quantum da pena aplicada impede a concessão da benesse disposta no art. 44, do CP, eis que fixada acima do limite legal de quatro anos, conforme prevê o inciso I do citado artigo. Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade encontra óbice na condição de reincidente que ostenta réu, nos exatos termos do artigo 44, inciso II, do CP. Assim, inviável aplicação de pena diversa da corporal.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Ademais, tendo em conta a pena aplicada, e o tempo de custódia que descontou até então, não faz jus a qualquer benefício.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu RAUL DOS SANTOS LOPES ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado. Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, nada, absolutamente nada vindo aos autos a indicar situação de hipossuficiência econômica do acionado.

Do contrário!

Desde o início vem sendo assistido por Defensor particular, de larga experiência, que, seguramente, não dedica todo conhecimento e estudo a título honorífico, circunstância indicativa, na minha modesta opinião, que o acionado, agora condenado, tem capacidade econômica suficiente a arcar com os custos da demanda, máxime em sendo proprietário (mesmo que por afirmada "herança") de bem imóvel de valor, donde, descabido o benefício da gratuidade de Justiça rogado.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei
Federal nº 11.419/06